# Capítulo 14

# La crisis migratoria y el derecho a tener derechos

## 14.1. La paradoja de los derechos del hombre

Si los derechos humanos pertenecen al hombre por el mero hecho de ser humano, resulta difícil explicar por qué el individuo queda en su situación de mayor indefensión precisamente cuando pierde todos sus atributos políticos y conserva únicamente su humanidad desnuda. Las declaraciones clásicas presuponían que la humanidad, sin aditamento alguno, basta para fundar una pretensión exigible. Quien pierde la ciudadanía, la nacionalidad y todo vínculo institucional con una comunidad política experimenta exactamente lo contrario: no el triunfo de esa humanidad desnuda como fundamento de protección, sino su fracaso práctico más radical. El apátrida no es menos humano que el ciudadano. Es, con frecuencia, jurídicamente menos real.

Ese contraste, que Hannah Arendt convirtió en el núcleo de su reflexión sobre el totalitarismo, funciona aquí como un experimento filosófico antes que como un capítulo de historia europea. La apatridia masiva que siguió a la Primera Guerra Mundial permite preguntar, con una nitidez que ninguna otra situación ofrece, qué

queda de los derechos humanos cuando desaparece la ciudadanía. La respuesta de Arendt fue incisiva: queda muy poco, y ese poco no basta. Correcta como diagnóstico, esa respuesta deja abierta una pregunta que Arendt no resolvió. Que la eficacia de los derechos dependa de la pertenencia política no implica que la pertenencia política sea su fuente. Confundir el fundamento de un derecho con su efectividad es uno de los errores más extendidos en la reflexión contemporánea sobre los derechos humanos, y deshacerlo es la tarea de este capítulo.

La pregunta puede formularse así: ¿pueden los derechos pertenecer realmente al ser humano en cuanto tal si su reconocimiento y su eficacia dependen, en la práctica, de pertenecer a una comunidad política que decide quién cuenta como miembro? Y en su forma más radical, la que Arendt rozó sin formular del todo: ¿puede existir un derecho a tener derechos sin un derecho correlativo a pertenecer a un Estado? Este libro ya ha respondido a la primera mitad de la pregunta. Al examinar el sujeto que el derecho no crea, estableció que el fundamento de los derechos fundamentales reside en la persona y no en la ciudadanía. Lo que queda por pensar, y lo que la experiencia del apátrida obliga a pensar, es la otra mitad: por qué, si el Estado no crea esos derechos, ha llegado a monopolizar casi por completo la maquinaria capaz de hacerlos exigibles. El drama del apátrida no demuestra que el Estado cree los derechos. Demuestra algo más inquietante: que la llave de su efectividad ha quedado casi enteramente en sus manos.

## 14.2. El apátrida y el derecho a tener derechos

El capítulo noveno de *Los orígenes del totalitarismo*, «La decadencia del Estado nación y el final de los derechos del hombre», no es un texto sobre política migratoria contemporánea (Arendt, 1951). Es un

intento de comprender qué sucedió entre 1918 y 1945 con millones de europeos que dejaron de tener un Estado que los reconociera, y qué revela ese acontecimiento sobre los derechos que la Ilustración había proclamado universales. Reducir su tesis a la afirmación de que la globalización debilita al Estado nación sería anacrónico, porque ese vocabulario pertenece a otra época, y empobrecería el problema, que no es sociológico sino filosófico y jurídico.

El punto de partida histórico es preciso. La disolución de los imperios austrohúngaro, otomano y ruso produjo en pocos años nuevos Estados construidos sobre el principio de las nacionalidades: cada nación debía tener su Estado, y cada Estado debía expresar a una nación. Las fronteras trazadas en Versalles y en los tratados sucesorios no coincidían, ni podían coincidir, con la distribución real de las poblaciones, y la respuesta institucional al desajuste fueron los tratados de minorías, que intentaron garantizar a esas poblaciones ciertos derechos sin concederles la nacionalidad plena del Estado en que vivían. Arendt vio con lucidez que esos tratados, lejos de resolver el problema, lo institucionalizaron: crearon residentes de segunda clase, protegidos sobre el papel por un derecho internacional incipiente y desprovistos en la práctica de un Estado dispuesto a defenderlos. De ahí nació, en cascada, el fenómeno que de verdad le interesaba: la desnacionalización masiva. Armenios expulsados del imperio otomano, rusos blancos que huían de la revolución, judíos alemanes despojados de su ciudadanía por las leyes de Núremberg se convirtieron en apátridas por decisión deliberada de un Estado. La institución que reconoce derechos se reveló también como la institución capaz de retirarlos mediante el simple expediente de negar la pertenencia.

Esas personas no perdieron derechos concretos, como el de votar o el de ejercer una profesión. Perdieron algo anterior, que Arendt llamó un lugar en el mundo que hace significativas las opiniones

y eficaces las acciones. Y ahí aparece la paradoja. Los derechos del hombre se presentaban como inalienables e independientes de cualquier gobierno; precisamente por eso deberían haber protegido con más fuerza a quien careciera de gobierno alguno. Ocurrió lo contrario. En el momento en que un ser humano dejaba de ser ciudadano de algún Estado y quedaba reducido a la mera condición humana, dejaba de tener derechos exigibles frente a nadie. «El hombre en cuanto hombre», con la ironía que Arendt puso en la expresión, resultó ser la abstracción menos protegida de todas.

Es en ese punto donde aparece la fórmula que da nombre al problema: el derecho a tener derechos. Arendt no la definió con la precisión que un filósofo del derecho exigiría, y su imprecisión ha alimentado una literatura considerable. Alison Kesby ha mostrado que admite al menos dos lecturas no del todo compatibles: el derecho a pertenecer a una comunidad política organizada, condición de cualquier otro derecho, y el derecho a que la propia acción y el propio discurso sean reconocidos como significativos por otros, sea cual sea la forma institucional de ese reconocimiento (Kesby, 2012). Seyla Benhabib ha insistido en que el núcleo del problema no es la ausencia de derechos sustantivos, sino la de un marco estable de pertenencia dentro del cual reclamarlos (Benhabib, 2004). Ayten Gündoğdu ha propuesto la lectura más fecunda para lo que sigue: la condición que Arendt describe no es la ausencia total de agencia política, sino una vulnerabilidad estructural desde la que los propios apátridas, mediante huelgas de hambre, protestas y peticiones, intentan constituirse en sujetos de derechos precisamente desde la posición que se los niega (Gündoğdu, 2015).

Esa lectura enlaza con la objeción más interesante que se ha dirigido contra Arendt, formulada con particular fuerza por Jacques Rancière. Para Rancière, el sujeto de los derechos del hombre no preexiste a su reclamación: se constituye políticamente en el acto

mismo de reclamar derechos que todavía no le son reconocidos, y el desacuerdo entre lo que un orden declara y lo que un excluido exige es el núcleo mismo de la política (Rancière, 2004). La objeción tiene fuerza real, porque los refugiados de entreguerras no fueron pura pasividad: se organizaron, protestaron y pidieron. Pero tiene también un límite que Arendt registró mejor que Rancière. La capacidad de reclamar un derecho no es la capacidad de hacerlo efectivo, y la distancia entre una y otra es exactamente la medida de la tragedia. La propia Arendt había descrito la dimensión existencial de esa distancia en «We Refugees», escrito en 1943 desde su experiencia de exiliada (Arendt, 1943): el refugiado se ve obligado a fabricarse una identidad pública, a menudo falsa o forzadamente optimista, para sobrevivir socialmente en un país que no lo reconoce, y lo que pierde no es solo un estatuto jurídico, sino la red de relaciones, reconocimiento y continuidad biográfica que hacen reconocible una vida humana.

Conviene precisar qué demostró Arendt y qué no. Demostró, con una evidencia histórica difícilmente refutable, que la efectividad de los derechos humanos dependió durante el siglo que ella analizó de la pertenencia a un Estado dispuesto a hacerlos valer. No demostró que el Estado sea su fuente, ni que la dignidad humana carezca de fundamento fuera de la ciudadanía, y atribuirle un positivismo radical sería injusto con su texto: Arendt no celebra que la ciudadanía sea condición de eficacia de los derechos, lo denuncia como una perplejidad trágica del orden moderno. Su propio análisis, además, presupone lo que no desarrolla. Si los derechos fueran pura creación estatal, la privación sufrida por el apátrida sería la consecuencia técnica de estar fuera del alcance de un ordenamiento, no una injusticia. Que Arendt la describa como injusticia revela que su diagnóstico descansa sobre un fundamento anterior a la decisión del Estado.

Este libro ha hecho explícito ese fundamento y no necesita reconstruirlo. Al distinguir la personalidad que un ordenamiento atribuye, modula o niega de la persona que ese ordenamiento encuentra ya ahí, estableció que negar a alguien posiciones jurídicas no lo priva de su condición de persona, del mismo modo que conceder personalidad jurídica a una sociedad mercantil no le otorga una vida interior. Lo que el caso del apátrida añade a aquella tesis es su prueba más cruda. El apátrida sigue siendo alguien cuando ningún Estado dice que lo es, y precisamente por eso su situación es una injusticia y no una consecuencia técnica.

Una distinción de Jacques Maritain ayuda a dar el paso siguiente. Maritain separó la persona humana, portadora de una dignidad que ninguna comunidad crea, de la persona cívica, la forma histórica y jurídica concreta en que esa dignidad se organiza dentro de una sociedad política determinada (Maritain, 1943). La distinción permite decir sin contradicción las dos cosas que Arendt parecía obligada a mantener en tensión: que la dignidad de la persona no depende de su pertenencia a ninguna comunidad cívica, y que el ejercicio efectivo de los derechos que esa dignidad funda requiere, en la práctica histórica, alguna forma de organización cívica. La pregunta que queda abierta es si esa forma tiene que ser el Estado nación.

La estructura del problema puede fijarse con una notación sencilla. Si $R(x)$ indica que $x$ posee determinados derechos fundamentales y $C(x)$ que posee ciudadanía, la tesis de este libro establece que la ciudadanía no equivale a la posesión del derecho,

$$C(x) \not\equiv R(x), \tag{14.1}$$

y que su ausencia no implica por sí sola la ausencia del fundamento del derecho:

$$\neg C(x) \not\Rightarrow \neg R(x). \tag{14.2}$$

La lección de Arendt obliga a añadir una relación que no es de necesidad lógica, sino de regularidad institucional observada. Si $E[R(x)]$ denota la efectividad institucional de $R(x)$, la ausencia de ciudadanía ha tendido históricamente a hundir esa efectividad, aunque no el fundamento:

$$\neg C(x) \Rightarrow E[R(x)] \downarrow . \tag{14.3}$$

Esta última expresión no es un teorema. Formaliza una regularidad histórica contingente, y es precisamente su contingencia la que abre la pregunta que ocupa el resto del capítulo: si esa regularidad es una necesidad institucional o la consecuencia de una organización histórica concreta del poder político, y por qué fue el Estado nación, y no otra forma de organización, el que llegó a concentrar la facultad de decidir quién pertenece y, con ella, la llave de los derechos que no había creado.

## 14.3. Nación, ciudadanía y el monopolio de la pertenencia

Buena parte de la fuerza persuasiva del diagnóstico arendtiano depende de una identificación conceptual que rara vez se examina de manera explícita: la que iguala nación, Estado, comunidad política y ciudadanía, como si se tratara de cuatro nombres para una misma realidad. Conviene desmontar esa identificación, no porque carezca de todo fundamento histórico, sino porque, tomada como necesidad conceptual, oscurece precisamente lo que aquí importa mostrar: que el modo en que el Estado moderno ha organizado la pertenencia política es una solución histórica contingente, no la

única forma imaginable de organizar la protección de los derechos.

Ernest Renan ofreció, en su célebre conferencia de 1882, una de las definiciones de nación más influyentes y, al mismo tiempo, más difíciles de reconciliar con una teoría sustancialista de la identidad nacional. Para Renan, la nación no es un hecho étnico, lingúístico o geográfico dado de antemano, sino «un plebiscito de todos los días»: una voluntad de vivir juntos, sostenida por una memoria compartida de glorias y, sobre todo, de duelos comunes (Renan, 1882). Esta definición, precisamente porque hace de la nación un acto de voluntad continuamente renovado, separa conceptualmente la nación del Estado: una nación en sentido renaniano puede existir sin ninguna organización estatal propia, como demuestran numerosos casos históricos de comunidades nacionales sin Estado, y un Estado puede, simétricamente, albergar en su territorio varias naciones en el sentido de Renan sin que ninguna de ellas coincida exactamente con las fronteras estatales.

Benedict Anderson completó este análisis desde una perspectiva distinta, al describir la nación como una «comunidad políticamente imaginada», cuyos miembros nunca conocerán a la inmensa mayoría de sus compatriotas pero se representan, gracias a mecanismos culturales concretos (la prensa impresa, la lengua vernácula estandarizada, los mapas y los censos), como partícipes de un mismo destino colectivo (Anderson, 2006). Anderson es útil aquí, además de por su tesis principal, por su insistencia en que esa imaginación colectiva no requiere necesariamente un aparato estatal para constituirse: puede preceder al Estado, como en los movimientos nacionalistas del siglo XIX que reclamaban un Estado precisamente porque ya se concebían como nación, o puede sobrevivir a su desaparición, como muestran numerosas diásporas nacionales sin territorio propio.

Ludwig von Mises, desde la tradición liberal austríaca, articuló

con particular claridad la distinción entre nación y Estado en *Nation, State, and Economy*, escrito en el contexto inmediato de la disolución del imperio austrohúngaro que tanto preocuparía después a Arendt (Mises, 1919). Mises sostenía que la nacionalidad es fundamentalmente una cuestión de lengua y de cultura compartida, y que exigir que cada nación posea su propio Estado territorial produce, en contextos de poblaciones mezcladas como el centroeuropeo, más conflictos de los que resuelve, porque convierte automáticamente en minoría oprimida a cualquier grupo nacional que quede del lado equivocado de una frontera trazada según el principio de las nacionalidades. En *Liberalism*, Mises extrajo la consecuencia institucional de este diagnóstico: la función legítima del Estado no consiste en expresar o proteger una identidad nacional sustantiva, sino en garantizar la paz, la propiedad y la libertad de sus habitantes, con independencia de su adscripción nacional (Mises, 1927).

Murray Rothbard llevó esta línea de análisis un paso más allá en «Nations by Consent: Decomposing the Nation-State», un texto que resultará central también para la discusión sobre migración más adelante. Rothbard distingue explícitamente entre nación, entendida como comunidad cultural, lingüística o histórica surgida espontáneamente, y Estado, entendido como aparato territorial de coacción organizada, y sostiene que la fusión histórica de ambos conceptos bajo la etiqueta «Estado nación» ha sido una construcción relativamente reciente y en absoluto necesaria (Rothbard, 1994). La consecuencia que Rothbard extrae de esta distinción, y que aquí se retoma sin necesidad de aceptar el resto de su programa teórico, es que una persona puede participar simultáneamente en múltiples formas de pertenencia (familiar, lingüística, religiosa, profesional, territorial) sin que ninguna de ellas requiera, para ser real y valiosa, el reconocimiento de un aparato estatal que la sancione.

De este conjunto de análisis se sigue una conclusión que convie-

ne formular con precisión porque será decisiva para lo que sigue: el Estado nación no es una necesidad ontológica de la vida política humana, sino una determinada solución histórica al problema de coordinar poder territorial, identidad nacional y ciudadanía jurídica, una solución que se consolidó en Europa fundamentalmente entre el siglo XIX y la primera mitad del XX y que Arendt analizó precisamente en el momento de su crisis más aguda. Reconocer esto no implica negar que, históricamente, el Estado nación haya sido, hasta ahora, la forma de organización política que con mayor eficacia ha garantizado derechos a sus miembros; implica, sencillamente, no confundir esa eficacia histórica contingente con una necesidad conceptual.

Esta distinción permite además introducir un problema que la identificación entre nación, Estado y ciudadanía tiende a ocultar: el de las comunidades superpuestas. Ninguna persona pertenece únicamente al Estado del que es ciudadana. Pertenece también, y con frecuencia de manera más intensa desde el punto de vista de su identidad personal, a una familia, a una comunidad religiosa, a un municipio, a asociaciones profesionales o culturales, a una lengua que puede no coincidir con la lengua oficial de su Estado, y a redes de cooperación voluntaria que exceden con mucho las fronteras estatales. La pertenencia política estatal es, en este sentido, una entre varias formas de pertenencia humana, no la única forma imaginable ni, necesariamente, la más fundamental desde el punto de vista de la identidad personal. Esta observación no resuelve todavía el problema arendtiano, porque es perfectamente compatible con reconocer que, en la práctica institucional contemporánea, sólo la pertenencia estatal lleva aparejada la capacidad de exigir derechos frente a terceros con la fuerza coactiva del derecho positivo. Pero sí despeja el terreno para la pregunta que sigue: quién decide, dentro de esa forma particular de pertenencia que es la ciudadanía estatal,

quién pertenece y quién no.

Toda teoría democrática presupone, antes de poder ofrecer ningún procedimiento de decisión colectiva, la existencia previa de un demos: un conjunto determinado de personas cuya voluntad, expresada según reglas mayoritarias o de otro tipo, se considera vinculante para todas ellas. Frederick Whelan formuló con particular claridad la dificultad que esta presuposición encierra, en un texto conocido en la literatura como el *boundary problem* de la teoría democrática (Whelan, 1983). El problema puede formularse en una sola frase: la democracia necesita un demos antes de poder aplicar sus propios procedimientos, pero es precisamente el demos quien decide, mediante esos mismos procedimientos o mediante decisiones anteriores a ellos, quién forma parte del demos.

La circularidad resulta, examinada con detenimiento, más profunda de lo que parece a primera vista. Supongamos que una comunidad política decide, mediante votación, ampliar o restringir los criterios de pertenencia a la ciudadanía. ¿quién tiene derecho a votar en esa decisión? Si sólo votan quienes ya son ciudadanos, la decisión sobre quién debe serlo en el futuro queda en manos exclusivas de quienes ya lo son, lo cual convierte a la ciudadanía en un club que decide unilateralmente sus propias condiciones de admisión. Si, para evitar esa objeción, se pretendiera que también votaran los aspirantes a la ciudadanía, se necesitaría ya un criterio previo para determinar quiénes cuentan como aspirantes legítimos, lo cual reintroduce el mismo problema en un nivel anterior. No existe, dentro de la lógica puramente procedimental de la democracia, un punto de apoyo desde el que resolver de manera no circular quién pertenece al demos llamado a decidir sobre la pertenencia.

Esta circularidad tiene una consecuencia directa sobre el problema arendtiano examinado aquí. El apátrida es, en el sentido más literal, la víctima paradigmática del *boundary problem*: es precisa-

mente la persona que quedó fuera del demos en el momento en que éste decidió sus propios límites, y que, por definición, no pudo participar en la decisión que la excluía porque todavía no perteneca al demos que la tomaba. Seyla Benhabib ha señalado con acierto que esta característica convierte a las decisiones sobre membresía en un tipo de decisión política estructuralmente distinta de las demás: mientras que, en cualquier otra política pública, quienes resultan afectados por una decisión tienen al menos, en principio, algún cauce de participación o de reclamación posterior dentro de la comunidad, quien resulta excluido de la membresía misma carece, por definición, de ese cauce (Benhabib, 2004). La exclusión de la pertenencia no es una política más entre otras: es la decisión que determina quién podrá, en el futuro, participar en la formulación de todas las demás.

Es importante no convertir esta observación en una crítica general e indiscriminada de la democracia como forma de gobierno, que no es el propósito de estas páginas ni de los capítulos que han examinado la relación entre voluntad colectiva y libertades individuales. El punto relevante aquí es más específico: ninguna mayoría democrática, por muy legítima que sea su autoridad dentro del ámbito de decisiones que le corresponde, posee un título evidente para decidir, sin ulterior justificación, quién cuenta como miembro moral y jurídicamente pleno de la comunidad. La legitimidad democrática presupone un demos ya constituido; no puede, sin caer en un círculo, fundamentar la constitución misma de ese demos.

Las respuestas que la tradición liberal clásica y libertaria han ofrecido a este problema merecen un examen crítico y no una aceptación acrítica. Mises y Rothbard coinciden en señalar la secesión y la fragmentación política como mecanismos capaces de aliviar, aunque no de resolver por completo, la concentración de la decisión sobre pertenencia (Mises, 1927; Rothbard, 1994). Su argumento tiene

una lógica interna consistente: cuanto menor es la escala territorial de una unidad política, y cuanto más abierta está la posibilidad de que subgrupos se separen de ella, menor es también el poder que cualquier mayoría puede ejercer sobre una minoría estructuralmente cautiva, porque la amenaza creíble de secesión funciona como límite disciplinador de la voluntad mayoritaria. Pero la secesión no resuelve el *boundary problem*; simplemente lo reproduce en una escala menor, porque toda unidad secesionada tendrá que volver a decidir, con los mismos problemas de circularidad, quiénes son sus miembros. Y, más gravemente para el problema específico que aquí importa, la secesión no ofrece ninguna respuesta directa al caso del apátrida, que no busca separarse de una comunidad política, sino ser admitido en alguna. El límite de la secesión como solución debe reconocerse explícitamente: alivia la concentración del poder de decidir sobre pertenencia, pero no elimina la necesidad de que, en algún nivel, alguna instancia decida quién pertenece y quién no.

La conclusión que se impone en este punto no es, por tanto, que el *boundary problem* carezca de solución institucional alguna, sino algo más modesto y, a la vez, más inquietante: que ninguna instancia democrática, por definición, puede resolverlo sin apelar a algún criterio de pertenencia anterior a su propio procedimiento. Ese criterio anterior tendrá que fundamentarse en algo distinto de la voluntad mayoritaria misma, lo cual reconduce el argumento, una vez más, hacia el fundamento prepolítico de la persona examinado más arriba. Si nada anterior a la decisión democrática limita qué puede decidirse legítimamente sobre la pertenencia, entonces no hay, en principio, ningún límite normativo a la capacidad de una mayoría para declarar apátrida a quien le convenga. Que esa conclusión resulte intuitivamente inaceptable es, precisamente, la mejor evidencia de que la dignidad personal opera como límite normativo previo a cualquier decisión sobre membresía, aunque

las democracias contemporáneas no siempre lo articulen con esa claridad.

Que ninguna instancia democrática pueda resolver sin circularidad quién pertenece no agota, sin embargo, el problema: falta examinar qué consecuencias aparecen cuando una organización territorial concentra simultáneamente la potestad de definir ciudadanía, nacionalidad, entrada, residencia, expulsión y buena parte de las instituciones mediante las cuales los derechos se hacen efectivos. No conviene repetir aquí el lugar común según el cual «el Estado es coercitivo», que nada explica sobre el problema específico de la apatridia; interesa, en cambio, examinar una función estatal muy concreta: la de clasificar administrativamente a las personas según categorías jurídicas discretas.

Murray Rothbard, en *Anatomy of the State*, ofrece una distinción útil para este propósito: la que separa el poder social, entendido como la capacidad humana de producir bienes y servicios mediante la cooperación voluntaria, del poder estatal, entendido como el control de los medios de coacción organizada dentro de un territorio determinado (Rothbard, 2009). Albert Jay Nock había formulado ya, en *Our Enemy, the State*, una distinción parecida entre «social power» y «State power», y había sugerido que buena parte de la historia política moderna puede leerse como la expansión del segundo a expensas del primero (Nock, 1935). Franz Oppenheimer, por su parte, había analizado ya a comienzos del siglo XX la formación histórica del poder estatal como resultado, en numerosos casos, de la conquista territorial y de la posterior organización de la extracción de recursos sobre poblaciones sometidas, más que como resultado de un pacto voluntario originario (Oppenheimer, 1926). Ninguno de estos autores es indispensable para el argumento específico de este apartado, pero todos comparten una misma sensibilidad: la de no dar por supuesto que el poder estatal sea, sin más, expresión

natural o necesaria de la voluntad de una comunidad.

El autor decisivo aquí, sin embargo, no pertenece propiamente a la tradición anarcocapitalista, sino a la sociología política comparada, y es James C. Scott. En *Seeing Like a State*, Scott desarrolla el concepto de legibilidad estatal para explicar por qué los Estados modernos han necesitado, históricamente, simplificar realidades sociales complejas en categorías administrativas discretas: apellidos fijos y hereditarios, catastros de propiedad, censos de población, registros civiles (Scott, 1998). Esa simplificación no responde, en la reconstrucción de Scott, a un capricho burocrático, sino a una necesidad funcional: ningún aparato administrativo puede gobernar, tributar o proteger aquello que no puede identificar y clasificar. La legibilidad es, en este sentido, condición de posibilidad de cualquier política pública a gran escala, incluidas las políticas de protección social que benefician a millones de personas.

Aplicado aquí, el concepto de legibilidad estatal ilumina por qué la categoría del apátrida resulta tan especialmente problemática dentro del orden jurídico internacional contemporáneo, aunque no en el sentido de que el sistema sea incapaz de nombrarla. El Estado moderno distribuye protección y pertenencia mediante un número limitado de categorías administrativas discretas: nacional, extranjero, residente legal, refugiado, apátrida, irregular. «Apátrida» es, precisamente, una de esas categorías: un estatuto jurídico reconocido por el derecho internacional, con una definición positiva propia, no una anomalía que el aparato clasificatorio del Estado sea incapaz de nombrar. La paradoja no reside, por tanto, en que el sistema no pueda clasificar al apátrida, sino en algo distinto: el sistema puede volverlo perfectamente legible, asignándole una casilla administrativa con nombre propio, y sin embargo esa legibilidad no resuelve su problema de pertenencia ni le garantiza una protección equivalente a la de las demás categorías del mis-

mo cuadro. Legibilidad no equivale a pertenencia, y clasificación jurídica no equivale a protección efectiva: el Estado puede volver administrativamente legible la anomalía sin eliminarla, y de hecho eso es exactamente lo que hacen los instrumentos internacionales examinados más adelante, que nombran con precisión al apátrida sin proporcionarle, la mayoría de las veces, un Estado dispuesto a asumirlo como nacional. La condición del apátrida no es, en consecuencia, la de un residuo inclasificable; es la de una categoría perfectamente clasificada cuya clasificación no lleva aparejada, salvo de manera muy incompleta, el haz de posiciones jurídicas que sí acompaña a las categorías vecinas. No es nacional de ningún Estado, no siempre encaja en la definición jurídica de refugiado, que exige un temor fundado de persecución y que se precisa más adelante, y su condición puede coexistir, paradójicamente, con la imposibilidad práctica de ser expulsado a ningún otro territorio que lo reclame como propio.

Conviene, siguiendo el propio espíritu del análisis de Scott, no presentar esta función clasificatoria como necesariamente maliciosa en su origen. La necesidad administrativa de categorizar es real, y ningún sistema de protección social o jurídica a gran escala podría funcionar sin algún grado de simplificación clasificatoria. El problema no reside, por tanto, en el hecho mismo de que exista una categoría jurídica llamada apatridia, sino en dos consecuencias ulteriores que la propia lógica de la legibilidad estatal, tal como la describe Scott, ayuda a explicar: primero, que la clasificación administrativa tiende a tratarse, con el tiempo, como si por sí sola resolviera el problema que nombra, en lugar de limitarse a hacerlo visible; segundo, que el haz de posiciones jurídicas efectivamente asociado a la categoría «apátrida» depende, en cada caso, de qué Estado la aplica y con qué grado de compromiso, de modo que ser correctamente clasificado no equivale a estar efectivamente

protegido, y esa distancia puede prolongarse durante generaciones enteras. James C. Scott ha explorado también, en *The Art of Not Being Governed*, cómo determinadas poblaciones han desarrollado históricamente estrategias deliberadas para sustraerse a la legibilidad estatal, replegándose hacia territorios de difícil acceso administrativo (Scott, 2009); ese material es útil aquí sobre todo como contraste, porque muestra que la ilegibilidad puede ser, en determinados contextos, una forma de autonomía buscada, mientras que la legibilidad del apátrida, precisamente porque no resuelve su problema de pertenencia, es una legibilidad casi siempre padecida.

Hans-Hermann Hoppe ha analizado, desde una perspectiva explícitamente crítica del Estado, el problema de la centralización política del monopolio territorial en *Democracy: The God That Failed* (Hoppe, 2001). Este argumento utiliza ese material de manera selectiva y no pretende adoptar la totalidad del programa hoppeano, que incluye tesis culturales y sociológicas notablemente más controvertidas y ajenas al problema específico de la apatridia. Lo que interesa retener de Hoppe es, exclusivamente, su análisis del monopolio territorial como estructura institucional: un único proveedor de servicios de protección y de definición de membresía sobre un territorio determinado carece, por definición, de competidores capaces de ofrecer un estándar alternativo de trato a quienes ese proveedor único decide excluir. Esta característica estructural del monopolio territorial es, precisamente, la que convierte la decisión estatal sobre pertenencia en una decisión sin apelación posible: si un único Estado niega la nacionalidad a una persona, y ningún otro Estado la reclama como propia, esa persona queda, en el sentido más literal, sin ningún lugar institucional al que dirigir su reclamación.

La conclusión de este recorrido puede formularse con precisión. El drama arendtiano del apátrida no se explica únicamente por la existencia de fronteras territoriales, que cualquier organización po-

lítica a gran escala parece requerir en alguna medida, sino por una característica más específica del Estado moderno: la concentración, en una única instancia territorial y sin competencia efectiva, tanto de la potestad de clasificar a las personas mediante categorías administrativas discretas como de la mayor parte de las instituciones mediante las cuales los derechos fundamentales se hacen valer. Esa doble concentración, no la existencia de fronteras en abstracto, es lo que convierte a la exclusión estatal en una forma de muerte jurídica prácticamente irrevocable.

## 14.4. Migración, propiedad y Estado del bienestar

Hasta aquí se ha examinado el problema de la apatridia como caso límite filosófico. Esta sección extiende el análisis hacia el debate contemporáneo sobre inmigración, sin identificar ambos fenómenos: el inmigrante, a diferencia del apátrida, suele conservar la nacionalidad de un Estado de origen dispuesto, al menos formalmente, a reconocerlo como nacional; su problema no es la ausencia de todo vínculo estatal, sino la dificultad de acceder a un vínculo distinto del que ya posee. La inmigración es, en este sentido, una extensión analítica del problema arendtiano, no una repetición de él: comparte con la apatridia la pregunta por quién decide sobre la pertenencia a un territorio, pero se plantea en condiciones jurídicas distintas.

Rothbard aporta a esta discusión un experimento conceptual particularmente útil. En «Nations by Consent», sostiene que la pregunta habitual, «¿debemos dejar entrar a los inmigrantes?», presupone sin examinarlo quién constituye exactamente ese «nosotros» y en virtud de qué título decide sobre todo un territorio (Rothbard, 1994). Rothbard invita a imaginar una sociedad en la que la propiedad del

territorio estuviera enteramente descentralizada entre propietarios individuales, y en la que, por tanto, no existiera ninguna decisión nacional única sobre inmigración, sino múltiples decisiones particulares de admisión, asociación, contratación y arrendamiento, cada una tomada por el propietario correspondiente. En ese escenario contrafactual, la pregunta «¿cuántos inmigrantes debe admitir el país?» carecería de sentido, porque no habría ningún sujeto colectivo con título para decidir sobre la totalidad del territorio; sólo habría decisiones individuales de admisión, tan legitimas o ilegitimas como cualquier otra decisión sobre el uso de la propiedad privada.

Jesús Huerta de Soto ha desarrollado un argumento complementario, centrado no en la descentralización de la propiedad territorial sino en la libertad contractual y de asociación (Huerta de Soto, 1998). Si una persona A desea contratar los servicios de B, alojarlo en su propiedad o simplemente relacionarse voluntariamente con él, y B desea entrar en el territorio donde A reside para hacer posible esa relación, ¿qué fundamento normativo tiene un tercero estatal, ajeno a la relación entre A y B, para impedirla? La fuerza de este argumento reside en que traslada la carga de la justificación: no exige demostrar por qué debería permitirse la inmigración, sino que exige, a quien pretende prohibirla, justificar por qué el Estado puede interponerse legítimamente en una relación voluntaria entre dos particulares. Huerta de Soto acompaña este argumento normativo de una advertencia institucional importante, que se retomará más adelante con mayor detalle: la libertad de movimiento no debe confundirse con un derecho automático a recibir cualquier prestación financiada coactivamente por terceros a través del Estado del bienestar. Esta distinción es coherente con el aparato hohfeldiano ya presentado: el derecho a moverse libremente y el derecho a recibir una prestación pública son posiciones jurídicas de estructura

distinta, y de la existencia de uno no se sigue automáticamente la existencia del otro.

Hans-Hermann Hoppe ha ofrecido, en «Natural Order, the State, and the Immigration Problem», un análisis institucional que distingue entre lo que llama micromigración y macromigración (Hoppe, 2002). La micromigración sería el desplazamiento de individuos particulares hacia comunidades que voluntariamente los invitan o admiten, sostenida por relaciones de propiedad y contrato; la macromigración sería el desplazamiento masivo, con frecuencia impulsado o al menos permitido por decisiones estatales centrales, que impone a comunidades receptoras concretas una integración forzosa con la que sus miembros no han consentido individualmente. El argumento institucional de Hoppe, despojado de sus afirmaciones sociológicas y culturales más controvertidas, que aquí no se adoptan ni se necesitan para la tesis defendida, puede resumirse así: el problema de la macromigración contemporánea no sería la inmigración en cuanto tal, sino la circunstancia de que un Estado centralizado decide, sobre un territorio que administra pero no posee en sentido pleno, quién entra y en qué condiciones, sin que quienes efectivamente conviven con los recién llegados hayan tenido, en la mayoría de los casos, ninguna forma de consentimiento particular sobre esa decisión.

Walter Block introduce en este punto un contrapunto interno indispensable, precisamente porque impide presentar al pensamiento libertario como un bloque homogéneo respecto de la inmigración. En «A Libertarian Case for Free Immigration», Block sostiene que buena parte del argumento hoppeano, al insistir en el consentimiento de las comunidades receptoras concretas, termina otorgando de facto a esas comunidades un poder de veto sobre la libertad de movimiento individual que resulta difícil de reconciliar con los principios libertarios de propiedad privada aplicados de manera

consistente: si un propietario particular desea alquilar su vivienda o emplear a un inmigrante, ningún tercero, incluida la comunidad circundante en su conjunto, tendría título legítimo para impedirlo (Block, 1998). El desacuerdo entre Block y Hoppe no es, por tanto, un desacuerdo entre libertarios y no libertarios, sino un desacuerdo interno sobre cómo aplicar consistentemente los mismos principios de propiedad y consentimiento, y no pretende zanjarse aquí, sino exhibirse como evidencia de que la tradición libertaria está lejos de ofrecer una única respuesta a la pregunta migratoria.

Joseph Carens representa, dentro de este debate, la posición cosmopolita más elaborada, y merece una exposición que no la reduzca a una caricatura. En *The Ethics of Immigration*, Carens argumenta que las fronteras estatales contemporáneas operan, en la práctica, de un modo estructuralmente análogo a los privilegios de nacimiento que las sociedades liberales han rechazado en otros ámbitos: el lugar de nacimiento de una persona determina, en gran medida y de manera arbitraria desde el punto de vista moral, sus oportunidades vitales, su acceso a instituciones eficaces y su nivel de protección jurídica (Carens, 2013). Carens no defiende una abolición inmediata de todo control fronterizo, pero sostiene que la carga argumentativa recae sobre quienes defienden restricciones a la libertad de movimiento, no sobre quienes la reclaman, y que muchas de las justificaciones habituales de esas restricciones no resisten un examen riguroso desde los propios principios liberales que los Estados que las imponen dicen profesar.

Christopher Heath Wellman ofrece la réplica más sistemática a esta posición, articulada sobre el principio de libertad de asociación. En «Immigration and Freedom of Association», Wellman sostiene que, de la misma manera en que un individuo tiene derecho a decidir con quién se asocia en su vida privada (a quién invita a su casa, con quién se casa, a quién admite en un club voluntario),

una comunidad política legítima y autogobernada tiene un derecho análogo, aunque no idéntico, a decidir quién se incorpora a ella como miembro pleno (Wellman, 2008). Wellman y Phillip Cole desarrollaron después este debate en un volumen conjunto que enfrenta explícitamente ambas posiciones bajo la pregunta «¿existe un derecho a excluir?», ofreciendo el contraste dialéctico más claro disponible en la literatura filosófica reciente entre la defensa de la autodeterminación comunitaria y la crítica cosmopolita a las fronteras cerradas (Wellman y Cole, 2011). David Miller ha reforzado, desde una posición menos libertaria que la de Wellman pero igualmente crítica de la apertura irrestricta, la idea de que las comunidades políticas poseen intereses legítimos, propios de su capacidad de autogobierno democrático y de su cohesión social interna, que justifican algún grado de control sobre su propia composición, sin que ese control equivalga a un derecho ilimitado de exclusión arbitraria (Miller, 2016).

La contribución específica de estas páginas a este debate, que ya cuenta con una bibliografía filosófica considerable, no consiste en zanjarlo en un sentido o en otro, sino en precisar exactamente qué pregunta está en juego y cuál no lo está. La pregunta que aquí puede responderse con el aparato conceptual desarrollado hasta ahora no es «¿deben abrirse o cerrarse las fronteras?», que exige ponderar consideraciones institucionales, culturales y políticas que exceden el propósito de este capítulo. La pregunta relevante es más precisa: ¿quién posee el título moral para decidir sobre la admisión, y qué relación existe entre propiedad, asociación, territorio, comunidad y autoridad estatal en la fundamentación de ese título? Frente a esa pregunta, la disputa entre Rothbard, Huerta de Soto y Block, de un lado, y Wellman y Miller, de otro, revela una tensión genuina entre dos principios que la tradición liberal suele profesar simultáneamente sin advertir su potencial conflicto: la libertad individual de

asociación y contratación, que apunta hacia decisiones de admisión descentralizadas, y el derecho de autodeterminación colectiva de las comunidades políticas, que apunta hacia algún grado de decisión centralizada legítima. Ninguno de los dos principios puede, por sí solo, reclamar prioridad absoluta sin generar consecuencias difícilmente aceptables: la prioridad absoluta de la asociación individual dejaría sin ningún instrumento a una comunidad para preservar rasgos colectivos que sus miembros valoran; la prioridad absoluta de la autodeterminación colectiva dejaría sin ningún instrumento al individuo para asociarse libremente con quien desee, incluso cuando esa asociación no lesiona a terceros.

Esa tensión se agrava, en las democracias contemporáneas, por la interacción entre movilidad y Estado del bienestar, que introduce una tercera variable que ninguna de las dos posiciones examinadas hasta aquí discute con el detalle necesario, y conviene abordarla con la prudencia empírica que el problema exige, distinguiendo tres tipos de argumento que suelen mezclarse sin advertirlo: el argumento normativo, sobre qué debería hacerse; el argumento institucional, sobre cómo interactúan dos instituciones concretas; y el argumento empírico, sobre qué efectos produce, de hecho, la inmigración sobre las finanzas públicas de un país determinado.

Huerta de Soto ha planteado con claridad el argumento institucional: la combinación de fronteras abiertas y un Estado del bienestar generoso puede generar, en teoría, incentivos migratorios distintos de los que generaría la combinación de fronteras abiertas y ausencia de prestaciones públicas condicionadas a la ciudadanía, porque una parte de los flujos migratorios podría estar motivada por el acceso a transferencias públicas y no únicamente por oportunidades de trabajo o de asociación voluntaria. Este argumento institucional es lógicamente coherente, pero conviene no convertirlo, sin evidencia adicional, en la afirmación empírica de que la

inmigración efectivamente observada colapsa o amenaza con colapsar el Estado del bienestar existente. Esa segunda afirmación exige contrastarse con datos, y los datos disponibles ofrecen un panorama más matizado del que la discusión pública suele presentar.

La OCDE, en su informe *International Migration Outlook 2021*, analiza el impacto fiscal neto de la inmigración en los países miembros y encuentra un panorama heterogéneo: el efecto fiscal neto varía considerablemente entre países y depende de manera decisiva de la composición del flujo migratorio, en particular de su estructura de edad, su nivel de formación y su tasa de participación laboral (OECD, 2021). Ian Preston, en un análisis metodológico influyente sobre el efecto de la inmigración en las finanzas públicas británicas, advierte que las estimaciones agregadas del impacto fiscal son extraordinariamente sensibles a decisiones metodológicas que rara vez se hacen explícitas en el debate público, como el tratamiento contable de los bienes públicos puros o el horizonte temporal considerado (Preston, 2014). Christian Dustmann y Tommaso Frattini, en un estudio empírico de referencia sobre el Reino Unido, encontraron que distintas oleadas migratorias han tenido contribuciones fiscales netas marcadamente distintas entre sí, positivas para algunos grupos y periodos, negativas para otros, lo cual desaconseja cualquier generalización única sobre «la inmigración» como categoría homogénea (Dustmann y Frattini, 2014). El informe de referencia de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos llega a una conclusión estructuralmente similar para el caso estadounidense: el impacto fiscal depende decisivamente de si se mide a nivel estatal o federal, del horizonte temporal de la proyección y de las características demográficas de los inmigrantes considerados, y no admite una respuesta única válida para todos los contextos (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017).

La conclusión empírica prudente, por tanto, es que el impacto fiscal de la inmigración es heterogéneo y depende de variables demográficas, laborales, generacionales, fiscales y metodológicas que impiden extraer, a partir de la evidencia de un país o un periodo determinado, una conclusión universal aplicable a cualquier otro contexto. Esta prudencia empírica no debilita, sin embargo, el argumento filosófico central de este apartado, que es de naturaleza distinta y no depende de cómo se resuelva la disputa empírica: ¿reconocer a una persona como sujeto de derechos implica reconocerle inmediatamente toda prestación positiva asociada históricamente a la ciudadanía política plena?

El aparato hohfeldiano permite responder que no, y permite además explicar con precisión por qué no, sin recurrir a una dicotomía entre derechos negativos y positivos que resultaría, examinada de cerca, excesivamente simple. Es tentador clasificar el derecho a no ser agredido, el debido proceso o la propiedad como derechos «negativos», que sólo exigirían abstención de terceros, y reservar la etiqueta de derecho «positivo» para la prestación pública financiada coactivamente. Pero el debido proceso no es, en su ejercicio real, una simple abstención: exige jueces, tribunales, procedimientos regulados y vías de recurso, es decir, un despliegue institucional tan costoso y tan positivo como el de cualquier prestación social. La propiedad tampoco se sostiene por sí sola una vez declarada: necesita definición legal, registro, adjudicación de conflictos y mecanismos coactivos de *enforcement* frente a terceros. La distinción relevante no es, por tanto, entre derechos que no cuestan nada y derechos que cuestan instituciones, porque casi todos cuestan instituciones en algún grado, sino entre posiciones hohfeldianas de estructura distinta. El derecho a no ser agredido es, en lo esencial, una pretensión (*claim*) frente a cualquier tercero indeterminado, correlativa de un deber universal de abstención que no presupone

la pertenencia del titular a ninguna comunidad de contribuyentes; el aparato institucional que lo hace efectivo, tribunales penales, policía, sistema de recursos, existe para tramitar su violación, no para constituirlo. El derecho a una prestación pública concreta es, en cambio, una pretensión frente a un sujeto obligado específico, normalmente el erario de un Estado determinado, cuya propia existencia como deudor depende de un sistema previo de financiación coactiva que, por definición, sólo puede sostenerse delimitando quiénes contribuyen a él y quiénes tienen título para reclamarlo. La pregunta relevante ante cada posición jurídica no es, entonces, si exige o no una institución, sino qué tipo de posición hohfeldiana está en juego, quién es su titular, quién es el sujeto correlativamente obligado, qué deber genérico frente a un círculo indeterminado de personas o frente a un deudor institucional específico, y qué institución resulta necesaria para hacerla efectiva. Esta heterogeneidad estructural, no una dicotomía simple entre lo negativo y lo positivo, permite separar con precisión dos expresiones que el debate público tiende a confundir: el *right to have rights*, en el sentido arendtiano de contar con un lugar institucional desde el que los derechos fundamentales de estatus puedan hacerse valer frente a un círculo indeterminado de obligados, y el *right to every benefit attached to full citizenship*, el derecho a toda prestación cuyo deudor específico es un sistema de financiación coactiva delimitado por la ciudadanía. Reconocer el primero a toda persona, con independencia de su nacionalidad, no exige comprometerse automáticamente con el segundo, y negar el segundo sin más justificación institucional no autoriza, simétricamente, a negar el primero.

## 14.5. ¿Necesita el derecho a tener derechos un Estado?

Lo dicho hasta aquí ha mostrado que el Estado moderno concentra, de hecho, buena parte de las instituciones mediante las cuales los derechos fundamentales se hacen efectivos. Queda pendiente una pregunta distinta: si los derechos no nacen del Estado, ¿necesitan necesariamente al Estado para hacerse efectivos? ¿Es necesariamente el Estado quien debe proporcionar ese «lugar en el mundo» al que remite la lectura arendtiana, o pueden existir formas alternativas, no estatales, de organización social capaces de cumplir una función análoga?

El poder social, ya distinguido del poder estatal en el apartado anterior, y las formas de organización comunitaria documentadas allí mismo a través de Scott, ofrecen un primer elemento de respuesta: ninguna de las dos depende, para existir, de que exista antes un Estado que las autorice. Friedrich Hayek, en «The Use of Knowledge in Society», aporta un segundo argumento, de naturaleza distinta, de orden epistemológico, que, aunque formulado originalmente para el problema económico del cálculo y la planificación centralizada, puede extenderse con cautela al problema institucional que aquí se examina: ningún planificador central, por bien intencionado que sea, puede poseer todo el conocimiento local y disperso necesario para coordinar de manera óptima las necesidades concretas de protección, reconocimiento y pertenencia de millones de personas particulares (Hayek, 1945). Este argumento funciona aquí, conviene precisarlo, como apoyo secundario y no como prueba concluyente: sugiere que la centralización estatal de la función protectora tiene costes epistémicos que rara vez se contabilizan, no que cualquier alternativa descentralizada sea automáticamente superior.

Interesa, en este punto, incorporar dos fuentes exploratorias adicionales, tratadas con la cautela metodológica que su naturaleza divulgativa exige. Miguel Anxo Bastos ha desarrollado, en distintas intervenciones sobre soberanía nacional, inmigración y formación histórica del Estado, una intuición institucional particularmente útil para cerrar este argumento (Bastos Boubeta, s.f.[b]; Bastos Boubeta, s.f.[a]). Esa intuición, que aquí se recoge únicamente en su estructura lógica y no como autoridad concluyente sobre ningún dato empírico concreto, puede formularse como un problema de *second best* institucional: si el orden institucional realmente existente puede describirse como una combinación de elementos $A + B + C + D$ (por ejemplo, fronteras estatales controladas, Estado del bienestar contributivo, mercado laboral regulado y vínculos comunitarios debilitados por décadas de sustitución estatal), no puede suponerse sin más que sustituir aisladamente un solo elemento, por ejemplo abolir el control fronterizo mientras los demás elementos permanecen intactos, produzca el resultado que produciría un orden institucional alternativo y coherente $a + b + c + d$, diseñado desde cero con esa misma lógica. Esta advertencia contra las reformas institucionales aisladas es metodológicamente valiosa con independencia de qué posición sustantiva se adopte finalmente sobre fronteras o bienestar, y se incorpora aquí precisamente para evitar la conclusión simplista, tan frecuente en el debate público, de que basta con abolir una única institución para obtener automáticamente los beneficios de un orden completamente distinto.

Esta consecuencia puede formularse como una extensión directa del material ya expuesto. Las intervenciones estatales no solo sustituyen funciones que antes desempeñaban instituciones comunitarias, familias extensas, mutualidades, asociaciones religiosas y vecinales; con el tiempo, pueden erosionar la capacidad misma de esas instituciones para reconstituirse cuando el Estado se retira o

resulta insuficiente. Si Nock tenía razón al distinguir poder social y poder estatal, y si Scott tenía razón al mostrar que comunidades no estatales pueden sostener funciones protectoras complejas, entonces la pregunta relevante no es sólo si el Estado debería monopolizar la función de garantizar el «lugar en el mundo» arendtiano, sino si décadas de sustitución estatal de esa función han dejado a la sociedad civil contemporánea en condiciones de recuperarla con la rapidez que un problema como la apatridia exigiría.

La respuesta posible a la pregunta que titula esta sección es, deliberadamente, parcial. No existe evidencia histórica contemporánea de que la sociedad civil, sin ningún tipo de coordinación jurídica formal, haya resuelto por sí sola, a la escala que el problema exige, la protección de millones de personas desprovistas de pertenencia estatal. Al mismo tiempo, tampoco existe ningún argumento conceptual que demuestre que el Estado territorial centralizado sea la única estructura institucional imaginable capaz de cumplir esa función; la historia registra órdenes policéntricos, comunidades de mutuo auxilio, redes religiosas transnacionales y formas de asociación voluntaria que han desempeñado, en contextos y escalas distintas, funciones protectoras parcialmente análogas. Lo que puede afirmarse con rigor es que la identificación entre «garantía efectiva de derechos» y «Estado territorial centralizado» es una identificación histórica contingente, sostenida por la experiencia reciente y no por ninguna necesidad conceptual, y que investigar seriamente sus alternativas exigiría un trabajo institucional propio que excede el propósito de este capítulo.

El análisis filosófico desarrollado hasta aquí necesita, sin embargo, una base jurídica mínima que lo confronte con la experiencia institucional real, y el orden jurídico internacional posterior a 1945 constituye, en este sentido, el intento más sistemático de institucionalizar una respuesta al vacío que Arendt identificó.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece, en su artículo 15, que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie se privará arbitrariamente de ella ni del derecho a cambiarla; los artículos 13 y 14 completan este marco con el derecho a la libre circulación dentro de las fronteras de cada Estado y el derecho a buscar asilo frente a la persecución (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). Es notable, y coherente con el diagnóstico arendtiano, que la propia Declaración reconozca de manera explícita el derecho a una nacionalidad, precisamente porque sus redactores, escribiendo pocos años después de la catástrofe de la apatridia masiva que Arendt había analizado, comprendieron que la carencia de nacionalidad no era un problema jurídico menor sino una amenaza estructural a la eficacia de todos los demás derechos declarados.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 define al refugiado como la persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país (Naciones Unidas, 1951). Esta definición no coincide con la de apátrida, y conviene precisar la distinción sin simplificarla en exceso: un refugiado puede conservar una nacionalidad, la de un Estado cuya protección no puede o no quiere reclamar por temor fundado a la persecución, mientras que un apátrida se define, con independencia de cualquier persecución, precisamente porque ningún Estado lo considera nacional conforme a su legislación. La nacionalidad formalmente conservada por el refugiado puede, en la práctica, resultarle tan inaccesible como si no la tuviera, lo cual explica que ambas categorías, junto con las del inmigrante regular y el extranjero en situación irregular, puedan solaparse en una misma persona

sin llegar nunca a confundirse conceptualmente. El derecho internacional las regula mediante instrumentos distintos precisamente porque generan obligaciones estatales diferentes.

La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 define específicamente a estos últimos como toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación (Naciones Unidas, 1954), y establece un catálogo mínimo de derechos que los Estados parte deben garantizar a los apátridas presentes en su territorio. Ese catálogo no equivale, en su diseño, al conjunto de derechos vinculado a la nacionalidad plena, puesto que se limita expresamente a un núcleo de protección mínima y remite en buena parte de sus disposiciones al trato dado a los extranjeros en general; una comparación precisa, artículo por artículo, con el catálogo reconocido a los refugiados por la Convención de 1951 excede el propósito de este apartado, y aquí basta señalar la asimetría de diseño sin cuantificarla. La Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961 complementa este marco desde una lógica preventiva, al establecer criterios que los Estados deben incorporar en su legislación de nacionalidad para evitar que nazcan nuevos casos de apatridia, especialmente entre menores nacidos en su territorio que de otro modo quedarían sin nacionalidad alguna (Naciones Unidas, 1961). El Manual del ACNUR sobre la Protección de las Personas Apátridas sistematiza la interpretación de estos instrumentos y ofrece criterios prácticos para su aplicación por parte de los Estados y de los propios órganos del sistema de Naciones Unidas (ACNUR, 2014).

La función de este entramado normativo, leído a la luz del argumento desarrollado hasta aquí, es doble y merece destacarse con precisión. Por un lado, constituye un reconocimiento explícito, por parte del derecho internacional positivo, de que la dignidad y los derechos fundamentales de la persona no dependen de la posesión

de una nacionalidad concreta, puesto que estos instrumentos obligan a los Estados a garantizar un catálogo mínimo de derechos precisamente a quienes carecen de ella; en este sentido, el derecho internacional de posguerra parece haber asimilado, al menos parcialmente, la distinción entre fundamento y ciudadanía defendida más arriba. Por otro lado, y de manera simultánea, la eficacia real de ese catálogo mínimo sigue dependiendo, en última instancia, de la voluntad de Estados soberanos concretos de incorporarlo, ratificarlo y aplicarlo efectivamente, sin que exista ninguna instancia supraestatal capaz de sustituir esa voluntad cuando falta. El propio ACNUR carece de capacidad coactiva directa sobre los Estados; su función es de asistencia, supervisión y promoción, no de ejecución forzosa.

El orden jurídico internacional posterior a 1945 no desarrolla, ni le corresponde desarrollar, una teoría filosófica del fundamento de los derechos; lo que ha logrado es articular un régimen jurídico de reconocimiento y protección de la persona apátrida que presupone, sin necesidad de argumentarlo explícitamente, que determinados derechos no desaparecen por el mero hecho de carecer de nacionalidad. Ese régimen no ha logrado, sin embargo, desplazar al Estado territorial de su posición como instancia última de efectividad institucional, lo cual confirma, desde el propio derecho positivo, la distinción entre fundamento filosófico, reconocimiento jurídico y efectividad institucional planteada al principio de estas páginas.

El problema filosófico se desplaza, al término de este recorrido, hacia una formulación precisa que no estaba disponible al comienzo: cómo construir instituciones capaces de garantizar derechos personales sin convertir la pertenencia a una determinada entidad política en condición constitutiva de la personalidad jurídica fundamental. Esta formulación conserva, deliberadamente, la tensión entre el diagnóstico arendtiano y la crítica prepolítica del funda-

mento de los derechos, en lugar de resolverla artificialmente en un sentido o en otro.

## 14.6. Los derechos no nacen del Estado, pero necesitan instituciones

El derecho a tener derechos no puede significar que el Estado conceda humanidad a quien carece de ella, porque la persona precede normativamente al Estado: esta es la tesis defendida desde el principio, apoyada en el personalismo, el derecho natural y la gramática hohfeldiana de las posiciones jurídicas, y que ningún paso posterior del argumento ha tenido que abandonar. Los derechos fundamentales no son, en este sentido, una creación ontológica del Estado; la persona no recibe su estatuto moral de la ciudadanía, sino que lo posee con independencia de ella. El derecho a tener derechos debe significar, más bien, que ninguna persona debería encontrarse en una posición en la que su exclusión de una comunidad política convierta en jurídicamente impotente una dignidad que aquella comunidad no creó. Esta formulación evita dos salidas fáciles rechazadas explícitamente en cada uno de los pasos anteriores: no concluye que necesitemos más Estado, como si la solución al drama del apátrida consistiera simplemente en ampliar las prestaciones y competencias del aparato estatal existente; tampoco concluye que debamos abolir el Estado, como si su mera desaparición resolviera automáticamente un problema que, según mostró la advertencia sobre el *second best* institucional, depende de la interacción compleja entre múltiples instituciones y no de una sola de ellas tomada de manera aislada.

Arendt demostró algo que ninguna filosofía del derecho natural puede desmentir sin caer en un idealismo ingenuo: un derecho sin instituciones capaces de hacerlo efectivo puede resultar, en la

práctica histórica, políticamente casi vacío. La tradición del derecho natural y el personalismo responden con igual razón que la comunidad política no puede ser la creadora última del derecho, porque entonces la injusticia sufrida por el apátrida dejaría de ser inteligible como injusticia y se convertiría en mera consecuencia técnica de estar fuera de un ámbito de aplicación. De ninguna de esas dos tesis se sigue, sin embargo, que el Estado nación territorial sea la única institución conceptualmente posible para garantizar derechos: la crítica libertaria y anarquista examinada más arriba añade una tercera consideración que ni Arendt ni la tradición iusnaturalista clásica desarrollaron con el mismo detalle institucional, y es que tampoco es evidente que el Estado territorial deba monopolizar, como de hecho lo hace, las formas mediante las cuales pertenencia, protección y asociación pueden organizarse.

El verdadero problema político, a la luz de todo lo anterior, no consiste en elegir entre más Estado o menos Estado, sino en separar aquello que la modernidad ha terminado identificando bajo una sola etiqueta administrativa: persona, ciudadanía, nación, Estado, pertenencia y protección jurídica. La crisis del apátrida no es, en este sentido, un accidente marginal del sistema internacional contemporáneo, sino la prueba más nítida de un peligro estructural: el de haber concentrado en una única institución, el Estado territorial, la facultad de decidir simultáneamente quién pertenece y qué protección recibe quien pertenece. Mientras esas dos decisiones permanezcan fusionadas en una misma instancia sin competencia ni contrapeso, quien queda fuera de la primera queda automáticamente fuera de la segunda, y el drama arendtiano del apátrida sigue siendo, estructuralmente, reproducible.

La dificultad final consiste, entonces, en pensar cómo hacer políticamente efectivos derechos cuyo fundamento no es político, sin convertir la pertenencia a una organización estatal determinada en

condición de humanidad jurídica. ¿Puede diseñarse un orden en el que los derechos sean políticamente efectivos sin hacer depender su existencia de la pertenencia obligatoria a un monopolio territorial? No hay aquí, ni se pretende ofrecer, una respuesta institucional completa a esa pregunta. Ofrecerla exigiría examinar con el mismo rigor aplicado a la apatridia otras propuestas institucionales, órdenes políticos policéntricos, comunidades voluntarias superpuestas, federalismo radical, mecanismos de secesión gradual, que ocupan el capítulo siguiente. Lo que sí se ha logrado, si el argumento es correcto, es despejar el terreno conceptual sobre el que esa investigación posterior debería construirse, distinguiendo con precisión lo que ninguna reflexión futura sobre la apatridia y la migración debería volver a confundir: el fundamento de un derecho, su reconocimiento positivo y su efectividad institucional.

# Bibliografía del capítulo


ACNUR (2014). *Handbook on Protection of Stateless Persons*. Ginebra.

Anderson, Benedict (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. revised. London: Verso.

Arendt, Hannah (1943). «We Refugees». En: *The Menorah Journal* 31.1, págs. 69-77.

– (1951). «The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man». En: *The Origins of Totalitarianism*. New York: Harcourt, Brace y Company.

Asamblea General de las Naciones Unidas (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Resolución 217 A (III), 10 de diciembre de 1948.

Bastos Boubeta, Miguel Anxo (s.f.[a]). *Imperios, naciones y política*. Intervención pública; plataforma y fecha exactas pendientes de verificación.

– (s.f.[b]). *La soberanía nacional y la inmigración*. Intervención pública; plataforma y fecha exactas pendientes de verificación.

Benhabib, Seyla (2004). *The Rights of Others: Aliens, Residents, and Citizens*. Cambridge: Cambridge University Press.

Block, Walter (1998). «A Libertarian Case for Free Immigration». En: *Journal of Libertarian Studies* 13.2, págs. 167-186.

Carens, Joseph H. (2013). *The Ethics of Immigration*. Oxford: Oxford University Press.

Dustmann, Christian y Tommaso Frattini (2014). «The Fiscal Effects of Immigration to the UK». En: *The Economic Journal* 124.580, F593-F643.

Gündoğdu, Ayten (2015). *Rightlessness in an Age of Rights: Hannah Arendt and the Contemporary Struggles of Migrants*. Oxford: Oxford University Press.

Hayek, Friedrich A. (1945). «The Use of Knowledge in Society». En: *The American Economic Review* 35.4, págs. 519-530.

Hoppe, Hans-Hermann (2001). *Democracy: The God That Failed. The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order*. Transaction Publishers.

– (2002). «Natural Order, the State, and the Immigration Problem». En: *Journal of Libertarian Studies* 16.1, págs. 75-97.

Huerta de Soto, Jesús (1998). «A Libertarian Theory of Free Immigration». En: *Journal of Libertarian Studies* 13.2, págs. 187-197.

Kesby, Alison (2012). *The Right to Have Rights: Citizenship, Humanity, and International Law*. Oxford: Oxford University Press.

Maritain, Jacques (1943). *The Rights of Man and Natural Law*. New York: Charles Scribner's Sons.

Miller, David (2016). *Strangers in Our Midst: The Political Philosophy of Immigration*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Mises, Ludwig von (1919). *Nation, State, and Economy*. Vienna.

– (1927). *Liberalism*. Jena.

Naciones Unidas (1951). *Convention Relating to the Status of Refugees*. 28 de julio de 1951, 189 UNTS 137.

– (1954). *Convention Relating to the Status of Stateless Persons*. 28 de septiembre de 1954, 360 UNTS 117.

– (1961). *Convention on the Reduction of Statelessness*. 30 de agosto de 1961, 989 UNTS 175.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2017). *The Economic and Fiscal Consequences of Immigration*. Washington, DC: The National Academies Press.

Nock, Albert Jay (1935). *Our Enemy, the State*. New York: William Morrow & Company.

OECD (2021). *International Migration Outlook 2021*. Paris: OECD Publishing.

Oppenheimer, Franz (1926). *The State: Its History and Development Viewed Sociologically*. Trad. por John M. Gitterman. New York: Vanguard Press.

Preston, Ian (2014). «The Effect of Immigration on Public Finances». En: *The Economic Journal* 124.580, F569-F592.

Rancière, Jacques (2004). «Who Is the Subject of the Rights of Man?» En: *South Atlantic Quarterly* 103.2/3, págs. 297-310.

Renan, Ernest (1882). «Qu'est-ce qu'une nation?» En: Conferencia pronunciada en la Sorbona el 11 de marzo de 1882.

Rothbard, Murray N. (1994). «Nations by Consent: Decomposing the Nation-State». En: *Journal of Libertarian Studies* 11.1, págs. 1-10.

– (2009). *Anatomy of the State*. Publicado originalmente en *Rampart Journal*. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.

Scott, James C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press.

– (2009). *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.

Wellman, Christopher Heath (2008). «Immigration and Freedom of Association». En: *Ethics* 119.1, págs. 109-141.

Wellman, Christopher Heath y Phillip Cole (2011). *Debating the Ethics of Immigration: Is There a Right to Exclude?* Oxford: Oxford University Press.

Whelan, Frederick G. (1983). «Prologue: Democratic Theory and the Boundary Problem». En: *Nomos XXV: Liberal Democracy*. Ed. por J. Roland Pennock y John W. Chapman. New York: New York University Press, págs. 13-47.